

TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS II

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A nomenclatura a ser utilizada pode ser “geração” ou “dimensão”. A diferença é que o termo “geração” é utilizado pela doutrina tradicional; “dimensão” é o termo utilizado pela doutrina mais moderna.

De acordo com a doutrina, uma geração substitui a outra, ao passo que as dimensões se acumulam. Seja como for, em uma prova discursiva, a sugestão é que o candidato utilize geração/dimensão, pois não há como saber qual é a preferência do examinador.

Para não errar a ordem das gerações/dimensões, o candidato pode se lembrar da associação feita pelo doutrinador Karel Vasak com o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.

- 1ª Geração/Dimensão (1789): “LIBERDADE” – abstenseísmo ou abstencionismo estatal (liberdades clássicas) → direitos civis (art. 5º da Constituição) e direitos políticos (arts. 14 a 16 da Constituição).

Obs.: a Revolução Francesa foi feita pela burguesia, que estava no meio da pirâmide social, entre a nobreza e o clero (ambos no topo) e os plebeus (base). A burguesia nada mais é do que o capitalismo e, por ter de sustentar os luxos da nobreza, decidiu que queria que o Estado saísse de cena. É nesse momento que surge o ideal da liberdade. A atuação negativa do Estado pode aparecer na prova como abstencionismo ou abstenseísmo estatal.

- 2ª Geração/Dimensão (1917-1919): “IGUALDADE” – *welfare state* ou estado do bem-estar social (direitos sociais, culturais e econômicos) → direitos sociais, culturais e econômicos (arts. 6º a 11 da Constituição).

Obs.: A partir da Revolução Industrial, passou a haver um descompasso entre patrão e empregado, de modo que os patrões cobravam jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia. Por influência da encíclica papal *Rerum Novarum*, a Constituição do México (1917) introduziu pela primeira vez os direitos sociais. Logo depois, o jurista Hans Kelsen escreveu as constituições da Áustria e da Alemanha, no contexto da devas-



5m

ANOTAÇÕES

tação provocada pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Com Kelsen, nasceu a ideia de que o Estado deveria oferecer suporte e estar presente, ou seja, atuar de forma positiva por meio de prestações sociais. Surge o conceito de igualdade em sentido material.

- 3ª Geração/Dimensão (década de 1970): “FRATERNIDADE” ou solidariedade – direitos trans/meta individuais, difusos ou coletivos (meio ambiente, consumidor, aposentadoria).



10m

Também existem direitos de 4ª Geração/Dimensão, embora as provas de concurso, em geral, cobrem até a 3ª. Observe:

- 4ª Geração/Dimensão: ligados a questões como globalização, clonagem, pesquisa genética, bioética, biodireito.
- 5ª Geração/Dimensão: direito à paz. É considerada uma dimensão utópica, pois a paz universal dificilmente será alcançada.

Décadas atrás, o doutrinador alemão Georg Jellinek desenvolveu uma teoria segundo a qual o cidadão, perante o Estado, se apresentaria de quatro formas diferentes. É a Teoria dos Quatro Status de Jellinek. Observe:

1. Status negativo (direitos civis): deriva dos direitos de 1ª Geração/Dimensão, com liberdades que nascem para proteger o cidadão contra abusos do Estado.

2. Status positivo: semelhante aos direitos de 2ª Geração/Dimensão, por meio da implementação de direitos sociais.

3. Status ativo (direitos políticos): a possibilidade de o cidadão intervir na vontade estatal. Exemplo: eleições, por meio de candidatos que apresentam modelos diferentes de pensar a máquina pública (um candidato pode propor um Estado mínimo, ao passo que outro pode propor um Estado mais inchado).



15m

4. Status passivo: a possibilidade de o Estado intervir na vontade de particulares (ou na relação entre particulares). Exemplo: quando veio para o Brasil, a companhia aérea Air France pagava para seus funcionários franceses o dobro do que pagava para os seus funcionários brasileiros. Quando a questão chegou ao STF, a corte entendeu que, embora seja uma empresa privada, a Air France não podia fazer essa distinção de nacionalidade, em obe-

ANOTAÇÕES

diência à Constituição, segundo a qual todos são iguais perante a lei. Essa decisão passou a servir de parâmetro para outras situações semelhantes, no que é chamado de eficácia irradiante dos direitos fundamentais. A eficácia irradiante objetivamente se espalha, reverberando em casos semelhantes.

Obs.: tempos atrás, uma decisão do STJ impediu a cobrança de taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet. Assim, naturalmente outros cidadãos passariam a querer aplicar a eficácia irradiante nos seus respectivos casos.



20m

Outro exemplo: quando voltou de uma viagem de avião, o professor Aragonê foi buscar o seu carro no condomínio onde morava e se deparou com o para-brisa quebrado. Ao ligar para o síndico, ele informou que, durante uma festa, alguns rapazes começaram a quebrar os para-brisas dos veículos, utilizando extintores de incêndio. Quando o síndico informou que já havia multado os rapazes, o professor Aragonê perguntou se ele havia dado aos garotos a oportunidade do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Indagado se estava querendo 'proteger bandidos', o professor informou que, de acordo com o entendimento dos tribunais, o condomínio pode aplicar multa apenas após respeitar o princípio do devido processo legal. É o mesmo princípio das multas de carro: primeiro, o motorista tem a oportunidade de se defender (tanto é que ela vem sem código de barras), e, depois, vem a cobrança com código de barras. O devido processo legal se estende para outras relações entre particulares, como a exclusão de um associado de uma associação, de um partido político, de uma sociedade etc.

DIMENSÕES DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Observe o quadro a seguir:

VERTICAL	É a dimensão clássica, segundo a qual o Estado está em posição de superioridade em relação aos seus cidadãos, de modo que os direitos fundamentais nascem para proteger os cidadãos dessa relação
	ESTADO PARTICULARES
HORIZONTAL	PARTICULAR – PARTICULAR.



25m

ANOTAÇÕES

TRANSVERSAL
ou DIAGONAL

Às vezes, a relação de ascendência de um particular sobre o outro é tão forte que não seria possível falar de eficácia horizontal. Exemplo: redes sociais (Instagram vs. usuário), em que o usuário é obrigado a concordar com os termos de uso para participar ou os casos em que ele pode ser arbitrariamente suspenso por alguma postagem.



Outros exemplos: direito do consumidor, direito do trabalho, imprensa (muitas vezes, a imprensa investiga, processa e julga em uma mesma reportagem). Embora exista o direito de resposta, este muitas vezes não recompõe o dano causado. Para exemplificar, certa vez o jornal *Correio Braziliense* noticiou que um médico denunciou o pai de um bebê que morreu, acusando-o de ter violentado o próprio filho. O acusado foi arrancado da cadeia por populares e, na sequência, linchado. Dezenove dias depois, o mesmo jornal informou que houve um erro: a criança golfou e engasgou. Como no engasgamento os orifícios se dilatam, o médico entendeu que a criança foi violentada, pois o ânus estava dilatado. O questionamento é: as pessoas que leram a primeira reportagem tiveram a oportunidade de ler a segunda? A indenização paga a dor do pai?

 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue os itens seguintes.
Os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada pela proteção de bens jurídicos de grupos sociais, como o patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 COMENTÁRIO

Os direitos fundamentais associados à solidariedade (fraternidade) são de 3ª Geração/Dimensão.

2. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.
Mais do que se prestarem à defesa do cidadão contra os poderes estatais, os direitos fundamentais impõem uma atuação positiva do Estado no sentido de concretizar determinados direitos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Revisar os direitos de 1ª e 2ª Geração/Dimensão.

GABARITO

1. C
2. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
